

DELIBERA N. 479 del 23 ottobre 2024

Oggetto

Istanza di parere ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 – SA istante: Ambito C06 – COMUNE DI AVERSA – OE: RTI Costituendo LA PIRAMIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per disabili non autosufficienti dei comuni dell'ambito C06 – CIG: A04600CB8B- Importo a base di gara: 615.800,00 euro.

UPREC-PRE-0218-2024-S-PREC

Riferimenti normativi

Art. 110, d.lgs. n. 36/2023

Artt. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 36/2023

artt. 155 c.p.c e 2963 c.c.

Parole chiave

Verifica di congruità dell'offerta – Procedimento – Richiesta delle giustificazioni – Termine – Natura acceleratoria

Verifica di congruità dell'offerta – Procedimento – Richiesta delle giustificazioni – Termine – Calcolo termini procedurali

Verifica di congruità dell'offerta – Procedimento – Giustificazioni – Invio da RTI

Massima

Appalto pubblico – Offerta economica– Verifica di congruità dell'offerta – Procedimento – Richiesta delle giustificazioni – Termine – Natura acceleratoria

L'art. 110 del d. lgs. n. 36/2023 disciplina la sequenza del subprocedimento di verifica dell'anomalia prevedendo una tempistica procedimentale stabilita dal legislatore, prevedente che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l'inoltro delle giustificazioni. La procedura delineata dal legislatore si basa su un termine acceleratorio, non superiore a quindici giorni, che evidenzia la necessità del superamento della prima parvenza di anomalia nel minor tempo possibile. È quindi necessario seguire il procedimento descritto all'art. 110 e, in particolare, la regola in base alla quale l'esclusione dell'operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di diritto europeo. L'impostazione accelerata della sequenza procedimentale si iscrive in un contesto di rispetto del principio del risultato, di cui all'art. 1 co. 1 del d. lgs. n. 36/2023, che costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.

Appalto pubblico – Offerta economica– Verifica di congruità dell'offerta – Procedimento – Richiesta delle giustificazioni – Termine – Calcolo termini procedurali



Ai sensi degli artt. 155 c.p.c e 2963 c.c., il termine per l'attivazione e il compimento del procedimento amministrativo va calcolato escludendo il dies a quo e comprendendo il dies ad quem, con la proroga di diritto della scadenza nel giorno festivo al giorno lavorativo seguente, tenendo conto che l'art. 155 c.p.c. equipara il sabato ad un giorno festivo. Tale disciplina generale dei termini procedurali è applicabile non solo al termine perentorio di cui all'articolo 101 del d.lgs. n. 36/2023, disciplinante il soccorso istruttorio, ma anche al termine acceleratorio di cui all'articolo 110 del d.lgs. n. 36/2023, relativo al procedimento di verifica di congruità dell'offerta.

Appalto pubblico – Offerta economica– Verifica di congruità dell'offerta – Procedimento - Giustificazioni – Invio dal mandante di un RTI

L'utilizzo in una procedura di gara del RTI, che non costituisce un nuovo ente dotato di personalità giuridica distinto dalle imprese che lo compongono, ma rappresenta un semplice modulo organizzativo basato sul mandato tra operatori, non può incidere sulla natura del soggetto partecipante. Ciò è confermato anche dal diritto unionale (cfr. direttiva 2014/24/UE), secondo cui i raggruppamenti di operatori economici partecipano di regola alle procedure di aggiudicazione senza dover assumere una forma giuridica specifica e possono subire l'imposizione di particolari condizioni solo ove proporzionate, non discriminatorie e giustificate da ragioni obiettive. È pertanto necessario dare un'interpretazione della lex specialis che sia in linea con i principi comunitari e non penalizzi la scelta di partecipare ad una gara in RTI.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 23 ottobre 2024

DELIBERA

VISTA l'istanza, relativa alla procedura per l'affidamento del contratto indicato in oggetto, acquisita con prot. n. 83399 del 16.07.2024, presentata dal Comune di Aversa, quale Capofila dell'Ambito 06, e successivamente integrata, previa richiesta per le vie brevi, con note prot. n. 89157 e prot. n. 89158 del 26.07.2024;

CONSIDERATO che l'istante Stazione appaltante rappresentava che, con nota del 03.06.2024, aveva inviato la Comunicazione ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023 alla RTI costituenda La Piramide-Giglio chiedendo l'invio dei giustificativi dell'offerta economica al fine di verificare la congruità dell'offerta economica con assegnazione di un termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione stessa e dunque entro la data del 08.06.2024 e che a tale richiesta era stato dato riscontro «dalla PEC del mandante e non del mandatario oltre il termine previsto e precisamente il giorno 9 giugno 2024, allegando riscontro con firma olografa dei concorrenti». La Stazione appaltante chiedeva dunque un parere all'Autorità in ordine al provvedimento di ammissione o esclusione del concorrente da adottare, ponendo sia la questione della natura perentoria o meno del termine ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, sia la questione della legittimità di un riscontro inviato dalla casella PEC della mandante e non della mandataria di un RTI costituendo;

VISTA la *lex specialis* che con riferimento alla disciplina delle offerte anomale rinviava al contenuto dispositivo dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato in data 04.09.2024 con nota prot. n. 101271;

VISTA, in particolare, la memoria del RTI La Piramide-Giglio, depositata con nota prot. n. 102779 del 09.09.2024 con la quale, a sostegno della correttezza del proprio operato e dell'ammissibilità delle giustificazioni presentate, la stessa rappresentava che «il termine concesso– al netto della sua brevità – tenuto conto anche delle numerose richieste presenti nella comunicazione [...], ricadeva, altresì, nel giorno di sabato. [...], che la Stazione appaltante [...] non esplicitava che si trattasse di termine a pena di



decadenza ed esclusione né il tipo di sottoscrizione da apporre al documento». Evidenziava inoltre che «La documentazione è stata trasmessa dalla mandante in nome e per conto dell'Rti "Piramide Giglio" anche in quanto la comunicazione ex art. 110 d. lgs. 36/2023 del 03/06/2024 è stata inviata e notificata anche alla mandante (Coop Giglio) e nella richiesta della Stazione appaltante non era espressamente richiesto l'invio di tale documentazione da parte della mandataria. Del resto, si aggiunge che, prima della formale costituzione del RTI, le imprese costituenti il costituendo raggruppamento non hanno ancora conferito alla capogruppo mandato irrevocabile a rappresentarla, ma mantengono la loro autonomia in termini di legittimazione ed interesse. [...] Pertanto, la pretesa di ricevere, in fase di gara e prima della formale costituzione del RTI, riscontro ed interlocuzione, esclusivamente dal soggetto designato quale capogruppo nella costituenda RTI, a pena di esclusione, non trova alcuna corrispondenza nella normativa di settore»;

VISTO il Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 220, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 36/2023, adottato con delibera n. 267 del 20 giugno 2023 e rilevato che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 9, del citato Regolamento;

CONSIDERATO che la questione controversa sottoposta all'Autorità attiene alla legittimità di un riscontro alla richiesta di giustificazioni dell'offerta avvenuto asseritamente allo scadere del termine previsto dalla Stazione appaltante e inviato dalla PEC della mandante anziché della mandataria;

VISTO il contenuto dispositivo dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2024;

CONSIDERATO che, la Relazione illustrativa al Codice, con riferimento all'art. 110, sancisce che: «*All'comma 2 si prevede che, qualora una determinata offerta appaia anormalmente bassa, è necessario in ogni caso sviluppare un contraddittorio procedimentale, richiedendo per iscritto al concorrente la presentazione di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, entro un termine non superiore a quindici giorni. Fermo il rispetto del termine massimo previsto dalla legge, il termine deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico*»;

RILEVATO che, con riferimento a tale disposizione, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, da ultimo con sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 13.08.2024 n. 7114, che «*L'art. 110 del d. lgs. n. 36/2023 disciplina la sequenza del subprocedimento di verifica dell'anomalia prevedendo che, in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni che ritiene necessarie, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni (comma 3). Ricevute le spiegazioni la Stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti (comma 5). La tempistica procedimentale stabilita dal legislatore prevede che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l'inoltro delle giustificazioni. La procedura è così delineata dallo stesso legislatore e si basa su un termine acceleratorio, "non superiore" a quindici giorni, che evidenzia la necessità del superamento della prima parvenza di anomalia nel minor tempo possibile. Detto termine, infatti, "deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico" ma "fermo il rispetto del termine massimo previsto dalla legge" (così la relazione al codice approvato con d. lgs. n. 36/2023). È quindi "necessario seguire il procedimento descritto all'art. 110 e, in particolare, la regola in base alla quale l'esclusione dell'operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di diritto europeo" (così la relazione al codice approvato con d. lgs. n. 36/2023), senza poter procedere ad alcuna esclusione automatica degli operatori economici (CGUE, sez. IV, 15 maggio 2008, C-147/06);*



RILEVATO che la stessa sentenza del Consiglio di Stato iscrive la disciplina procedimentale di cui all'art. 110 nel quadro dei principi generali delineati dal Codice stesso e, in particolare, sottolinea come «*L'impostazione accelerata della sequenza procedimentale [...] si iscrive in un contesto di rispetto del principio del risultato, in base al quale le stazioni appaltanti "perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo" (art. 1 co. 1 del d. lgs. n. 36/2023). Lo stesso articolo prevede espressamente che il principio del risultato "costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto" (comma 4). Pertanto, soccorrono specifiche regole di gara a presidiare il rispetto della sequenza e della tempistica procedimentale sopra delineata, regole che risultano coerenti con il principio di autoresponsabilità che informa le procedure di evidenza pubblica, nelle quali la partecipazione è condizionata a un'istanza del soggetto interessato, portatore di un interesse pretensivo che è affidato alla cura del medesimo, compulsato a evidenziare le proprie aspirazioni nel modo migliore e aderente alla legge di gara dalle stesse regole della competizione (che fra più aspiranti allo stesso bene della vita premiano il più performante). [...] Né la disciplina di settore impone alla Stazione appaltante di reiterare la richiesta già formulata con la nota di avvio della verifica di anomalia. In base alla regola dettata dall'art. 110 co. 5 del d. lgs. n. 36/2023, "la Stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti", che comprende anche il caso in cui le spiegazioni fornite non giustificano l'offerta, non comprendendo tutti i dati richiesti dalla Stazione appaltante per superare il primo giudizio di anomalia ("appaia anormalmente bassa", così l'art. 110 co. 1 del d. lgs. n. 36/2023). Né detta condizione è meramente formale, nel contesto procedimentale delineato, anche in punto di tempistiche, dall'art. 110 del d. lgs. n. 36/2023, in quanto, atteso che "spetta all'offerente fornire nell'ambito del contraddittorio procedimentale le prove documentali a supporto della asserita sostenibilità della sua offerta ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016" (Cons. St., sez. V, 28 giugno 2021 n. 4867) e che è previsto un termine "massimo" (così come sopra anticipato) per il riscontro istruttorio alla richiesta di giustificazioni, ne deriva che la mancata comprova di detta sostenibilità non consente di superare la (precedente) valutazione che ha determinato la sottoposizione dell'offerta alla verifica di anomalia, cioè che l'offerta "appaia anormalmente bassa". Del resto, se si consentisse di produrre, oltre il termine assegnato, la documentazione richiesta con la nota che ha dato avvio alla verifica di anomalia, verrebbe meno la funzione (acceleratoria) del termine "massimo". Pertanto, considerato quanto sopra, l'offerente non può pretendere che la Stazione appaltante, che deve assicurare "il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività", assegni un ulteriore termine per il supplemento istruttorio, peraltro a un soggetto che neppure ha dato conto di un'eventuale difficoltà di reperimento del documento o di elementi nuovi o sopravvenienze (e senza quindi che sia necessario valutare la rilevanza, o meno, di un'eventuale comunicazione in tal senso)» (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato n. 7114/2024, citata);*

RITENUTO che, in linea con il richiamato orientamento ermeneutico, il termine ex art. 110, stante la finalità cui è deputato, abbia natura prettamente acceleratoria;

RILEVATO che il tenore letterale dell'art. 110 dispone l'esclusione dell'offerta nel caso in cui le spiegazioni fornite non giustifichino adeguatamente l'offerta stessa mentre non dispone invece l'esclusione nell'ipotesi del mancato riscontro entro i termini previsti dalla Stazione appaltante a differenza di quanto espressamente previsto al comma 2 dell'art. 101 in materia di soccorso istruttorio in cui il legislatore ha optato per stabilire una causa di esclusione esplicita: «l'operatore economico che non adempie alle richieste della Stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla gara»;

RITENUTO che tale differenza nella scelta legislativa, in ragione del principio giuridico «*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*» sia indice del fatto che il legislatore ha voluto distinguere le due fattispecie giuridiche con riferimento sia alla natura del termine, sia alla sanzione prevista per il relativo mancato rispetto;



RITENUTO che, nel caso di specie, posta tale ricostruzione giuridica, il termine di cinque giorni previsto dalla Stazione appaltante abbia natura acceleratoria e il riscontro, asseritamente avvenuto oltre tale termine, non possa costituire di per sé causa di esclusione ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, rileva altresì l'ulteriore circostanza per cui il termine imposto dalla Stazione appaltante ricadeva nella giornata del sabato, ponendo pertanto, ai fini della definizione della controversia, anche l'ulteriore questione della disciplina da applicare al calcolo dei termini procedurali;

CONSIDERATO che recentemente la giurisprudenza amministrativa, sebbene con riferimento al procedimento di soccorso istruttorio il cui termine è perentorio, ha chiarito con sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 03/05/2024, n. 8791, che *«Ai sensi degli artt. 155 c.p.c e 2963 c.c., il termine per l'attivazione e il compimento del procedimento amministrativo va calcolato escludendo il dies a quo e comprendendo il dies ad quem e con la proroga di diritto della scadenza nel giorno festivo al giorno lavorativo seguente, tenendo conto che l'art. 155 c.p.c. equipara il sabato ad un giorno festivo»* (TAR Ancona n. 18/2015). *Tale termine di dieci giorni, entro il quale l'impresa concorrente è tenuta ad ottemperare alla richiesta della Stazione appaltante ha carattere perentorio, per cui la sua inosservanza determina l'esclusione del concorrente interessato. Tuttavia, i criteri di computo dei termini del procedimento amministrativo sono quelli che si rinviengono nella disciplina generale dettata dagli artt. 155 ss. c.p.c. e 2963 c.c.»*;

RITENUTO che, se la disciplina generale dei termini di cui agli artt. 155 ss. c.p.c. e 2963 c.c. è stata ritenuta applicabile al caso del soccorso istruttorio ex art. 101 il cui termine, come sopra ricostruito, è un termine perentorio per specifica scelta legislativa, tale disciplina si ritiene applicabile *a fortiori* al caso del termine del procedimento di verifica di anomalia ex art. 110, la cui natura è acceleratoria. Ne consegue che per il calcolo dei termini procedurali della verifica di congruità dell'offerta trova dunque applicazione il principio per cui il termine va calcolato escludendo il *dies a quo* e comprendendo il *dies ad quem*, con proroga di diritto della scadenza nel giorno festivo al giorno lavorativo seguente;

RITENUTO che pertanto, nel caso di specie, in applicazione di tale dei termini procedurali, il termine dei cinque giorni imposti a decorrere dal 03.06.2024, che scadeva il giorno 08.06.2024, ovvero un sabato, deve essere prorogato di diritto al successivo lunedì, ovvero il 10.06.2024. Ne consegue, pertanto, che il riscontro avvenuto in data 09.06.2024, è da considerarsi, anche per tale ragione, legittimo;

CONSIDERATO che, con riferimento all'ulteriore questione sollevata dalla Stazione appaltante istante relativa alla legittimità del riscontro dei giustificativi inviato dalla PEC della mandante e non della mandataria, rileva evidenziare che è unanime il principio, da ultimo espresso in Consiglio di Stato, sez. IV, 30.05.2024 n. 4846 secondo cui *«L'utilizzo in una procedura di gara del RTI, che non costituisce, in verità, un nuovo ente dotato di personalità giuridica distinto dalle imprese che lo compongono, ma rappresenta un semplice modulo organizzativo basato sul mandato tra operatori, non può, dunque, incidere sulla natura del soggetto partecipante, [...] Ciò è confermato anche dal diritto unionale (cfr. direttiva 2014/24/UE), secondo cui i raggruppamenti di operatori economici partecipano di regola alle procedure di aggiudicazione senza dover assumere una forma giuridica specifica e possono subire l'imposizione di particolari condizioni solo ove proporzionate, non discriminatorie e giustificate da ragioni obiettive. Da qui la necessità di un'interpretazione che sia in linea con i principi comunitari e non penalizzi la scelta di partecipare ad una gara in RTI»*;

RITENUTO che, ai fini della risoluzione della questione posta nell'odierna controversia, soccorra ancora una volta il principio sostanzialistico sopra richiamato e la necessità di dare un'interpretazione alla *lex specialis* e alla documentazione della Stazione appaltante che sia il più possibile in linea con i principi comunitari e non penalizzi la scelta di un operatore economico di partecipare ad una gara in RTI: infatti, nel caso di specie, l'Amministrazione, pur non fornendo indicazioni esplicite in merito alle condizioni di riscontro, ha correttamente inviato la richiesta ex art. 110 ad entrambi i componenti del RTI costituendo,



essendo l'offerta presentata da entrambi ed essendo un eventuale provvedimento espulsivo a potenzialità lesiva per l'intero raggruppamento, tuttavia tale comunicazione non può che essere interpretata in conformità ai principi sopra richiamati, ritenendo quindi legittima la modalità di presentazione delle giustificazioni da parte del concorrente;

RITENUTO che, ad ulteriore conferma di tale criterio interpretativo depone altresì il fatto che il procedimento di verifica della congruità dell'offerta di cui all'art.110 del d.lgs. n. 36/2023 è specificamente volto ad una verifica in concreto del contenuto delle giustificazioni non potendo costituire motivo di esclusione l'invio della documentazione da parte della PEC della mandante e non della mandataria,

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, l'avvenuto invio delle giustificazioni dalla PEC della mandante e non della mandataria non possa costituire legittima causa di non ammissione delle giustificazioni stesse e di esclusione del concorrente, in ragione dell'esplicito tenore letterale dell'art. 110, sopra ampiamente delineato, e dei principi, anche eurounitari, relativi ai raggruppamenti;

RITENUTO pertanto che, alla luce delle argomentazioni giuridiche sopra richiamate e dei principi generali in materia di contratti pubblici, *in primis* il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante è tenuta a ritenere le giustificazioni all'offerta inviate dal concorrente conformi alla disciplina di gara, alla comunicazione inviata e all'art. 110, con riferimento sia al termine di adempimento sia al mittente;

RITENUTO altresì che spetti poi alla Stazione appaltante, nell'ambito dei perimetri discrezionali che l'ordinamento le riconosce ed in attuazione del contenuto dispositivo di cui all'art. 110, valutare nel merito la congruità dell'offerta presentata in ragione delle giustificazioni depositate e, solo qualora tale verifica si concluda con esito negativo, procedere all'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023;

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono e limitatamente alla questione esaminata, che la modalità di presentazione delle giustificazioni da parte dell'operatore economico, con riferimento al termine di adempimento e al mittente che le ha inviate, sia conforme ai principi in materia di contratti pubblici e all'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e che spetti, nel merito, alla Stazione appaltante la relativa valutazione ai fini della verifica di congruità dell'offerta.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 ottobre 2024

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente